

1500459-02.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500459-02.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500459-02.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063157/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 23438027 - 01º D.P. AMERICANA, 427/22/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2063157 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO PAULINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

APARECIDO PAULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada, subtraiu, para si, 05 (cinco) barras de ferro avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à empresa "FLM MONTAGENS INDUSTRIAIS".

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (fls. 160/161).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 177).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 205/206).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 210/211), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

O Doutor Defensor do réu requereu a absolvição ante princípio da insignificância ou o reconhecimento da atenuante e a fixação de regime mais brando (fls. 212/215).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 07/09, 10/13 e 15/22, e laudo de fls. 151/155.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás

Banzhaf, 1ª ed., EJEa, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmutara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A testemunha/vítima Aelson, representante da pessoa jurídica, informou que foi comunicado pelo vizinho da empresa que alguém tinha pulado no estabelecimento, sendo que a polícia foi acionada e o indivíduo apreendido. Disse, ainda, que reconheceu o objeto subtraído como de sua propriedade. Por fim, informou que o local é cercado por alambrado, de cerca de dois metros e meio de altura, possuindo portão com cadeado.

Não há nos autos prova de que a testemunha conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que realizaram a investigação e terminaram por deter o réu.

Os guardas municipais esclareceram que encontravam-se em patrulhamento quando receberam a informação de que um indivíduo, com uma carroça e um cavalo, teria adentrado o barracão de uma empresa, pulando o portão, e subtraído materiais. Disseram, ainda, que dirigiram-se até o local, e efetuaram a abordagem. Em revista, nada de ilícito foi localizado, mas na carroça, encontraram cinco barras de ferro, as quais foram reconhecidas pelo proprietário. Verificaram, também, a irregularidade com o animal, ante uma lei municipal impedindo que cavalo puxe

carroça, razão pela qual foi recolhido por uma ONG. Indagado, o réu confirmou que havia pulado o alambrado. Por fim, o estabelecimento era cercado por um alambrado, sendo que o portão possui razoável altura.

O réu Aparecido, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto. Declarou que trabalha recolhendo recicláveis, e viu umas latinhas e os pedaços de barra, pulou o muro e pegou os objetos.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

“É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem” (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca das qualificadoras.

Ainda, a qualificadora da escalda encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 151/155, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

No mais, não há que se falar em crime de bagatela ou insignificância, figura desconhecida no nosso ordenamento jurídico. O pequeno valor da coisa não serve para legitimar o comportamento em questão, mas apenas para eventual abrandamento de pena em caso de furto privilegiado, o que não ocorreu no presente caso.

Na doutrina de Júlio Fabrini Mirabete:

“A excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserida na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 3/345) .

(...) Segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência

nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial. (Manual de Direito Penal, 21a. Ed. vol. I, p. 118/119)

E o próprio Mirabete exemplifica:

"É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja o efetivo desfalque do patrimônio alheio". (Idem, vol.II, pág.225/226).

O Desembargador Souza Nery, de forma assaz pertinente, assim coloca a questão:

"Quanto à tese do crime de bagatela, entendo que não se aplica ao caso o chamado princípio da insignificância. O ordenamento jurídico brasileiro não contemplou – malgrado o desejo de muitos – o princípio da bagatela, a cujo respeito já se disse decorrer de verdadeira insignificância de princípios." (TJSP – AC - 990.09.058638-9, 9ª Câmara Criminal, j. 27.08.09).

Da mesma forma, o Desembargador Xavier de Aquino entende que a pequena quantia subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada não tornam atípica a conduta, embora possam, desde que presentes outros requisitos, permitir o reconhecimento do furto privilegiado. De acordo com o eminente Magistrado:

"Pensar de forma diferente seria transformar as ruas em palco de treinamento para delinquentes. Se apanhados permanecem impunes diante da aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, se a conduta é bem sucedida também saem ilesos". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 990.09.218713-9, Americana, 11ª Câmara Criminal, j. 09.12.2009).

Em julgado da apelação nº 0001914-88.2012.8.26.0581, da Comarca de São Manoel-SP, assim decidiram nossos tribunais.

"Tocante à aplicação do princípio da insignificância, deve-se ter em mente que o fato não pode ser considerado atípico somente em decorrência do valor da coisa furtada, ou porque os bens foram recuperados. Para tanto, creio ser indispensável a presença de outros requisitos estabelecidos pela doutrina e pela Jurisprudência: 1) ofensividade mínima; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade; 4) inexpressividade da lesão jurídica causada (STF, HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/05/10; STJ, REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14/06/10; HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de 15/03/10).

O réu é reincidente (certidões de fls. 11/12 do autuado em apenso), ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF "O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal", HC 102.088, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/05/10.

Não se pode confundir baixo grau de lesividade com sua absoluta inexistência, pena de adotar-se, como regra, a impunidade em casos como os em comento. Daí porque se justifica a "persecutio criminis in juditio".

Nos dias atuais, em que a sociedade presencia o recrudescimento de toda espécie de criminalidade, em que as instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela

manutenção da segurança e ordem pública sofrem com o descrédito da população, em que a sensação de insegurança está pulverizada em todo o corpo social, o princípio da insignificância deve ser aplicado com redobrada cautela, devendo constituir exceção e não regra, pois do contrário o Judiciário estará alimentando esse sentimento de desassossego, fomentando o crime e a impunidade. Pelo que tenho notado a jurisprudência não se pacificou com relação à incidência do princípio. Pelo contrário, atualmente tem passado a analisar o crime sob o enfoque da vítima, sob o prisma de quem está perdendo _ e para quem, via de regra, a conduta é dotada de lesividade. Nesse sentido pronunciou-se o Min. Luiz Fux no julgamento do HC nº 100.690 (Supremo Tribunal Federal): "Eu tenho muita preocupação com essa teoria, porque as jurisprudências dos tribunais têm um caráter exemplificativo para a sociedade. Então, se nós chegamos aqui para dizer que furtar dois DVD's não é crime, nós estamos exatamente tornando antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita". (AC 2014.0000633914, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Orlando, 06.10.2014).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PENAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DA RES PALAVRAS DE TESTEMUNHAS RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL - PENA E REGIME REESTRUTURADOS - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da insignificância, porquanto constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurídicos. - Estando comprovada a autoria do delito pela confissão do agente, apreensão da res furtiva em seu poder e depoimento de testemunhas, a condenação é medida que se impõe. Sendo a apelante primária e a res furtiva de pequeno valor é de se reconhecer o furto privilegiado na espécie nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação nº 990.09.366733-9 - 12ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi - j. 19.05.2010)

FURTO - Bem subtraído que possui valor econômico, ainda que pequeno - Reconhecimento de crime de bagatela - Impossibilidade: 52(a) - Quando o bem subtraído possui valor econômico, ainda que pequeno, é impossível o reconhecimento do crime de bagatela, não se caracterizando o delito do art. 155 do CP apenas quando não se puder avaliar o produto do furto diante da insignificância da lesão jurídica, como na subtração de um ovo, de ramas de mandioca, de folhas de palmeira etc. (Apelação nº 1.101.025/3, Julgado em 14/09/1.998, 12ª Câmara, Relator: José Habice, RJTACRIM 41/170).

No mais, a existência da prática reiterada de crimes, comprovado nos presentes autos com a reincidência e/ou maus antecedentes, impossibilita a análise do referido benefício.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.194/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BEM DE VALOR CONSIDERÁVEL. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A conduta narrada nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, pois o valor do bem subtraído não se revela ínfimo, correspondendo a cerca de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo certo que o furto em questão não representa fato isolado na vida do paciente, que já foi condenado por crime semelhante, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa. 3. (...). (HC n. 330.156/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 10/11/2015.)

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu Aparecido possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 73/98) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto qualificado (escalada), há maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base, em 1/6 (um sexto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA

JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é, também, reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 73/98. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto em razão de ser o réu reincidente.

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu APARECIDO PAULINO às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.
P. I. C.

Americana, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA